

1021530-92.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: José Renato da Silva Ribeiro

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública

Rua Jose Ruiz Pelegrina, 6-60, Bauru-SP - cep 17018-620

1021530-92.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1021530-92.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Marcial Oliveira Beraldo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e DECIDO.

Aplica-se ao caso concreto a norma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Trata-se de pedido condenatório em pecúnia consistente na reparação por danos morais no importe de R\$ 10.000,00. Em síntese, o autor relata danos morais decorrentes de constrangimentos e ilegalidade supostamente advinda da omissão na apreciação pelo Poder Judiciário, pois faria jus à progressão do regime fechado para o semiaberto desde abril de 2017, mas somente obteve acesso a esse direito em maio de 2021.

O pedido não procede. Vejamos.

Entendo que a questão posta aos autos está afinada a responsabilidade civil pela atividade jurisdicional, em ato judicial típico. A execução penal é ato judicial típico, não havendo que se falar em atos do Poder Executivo, muito embora, não no caso concreto, isso também possa ocorrer. No caso em tela, entretanto, são

avaliações do sentenciado vistas pelo juízo competente, o juízo de primeiro grau da Vara das Execuções.

Sobre o tema, vejamos a doutrina sempre preponderante de SÉRGIO CAVALIERI FILHO (14ª edição, p. 317 e ss):

“Nem sempre será tarefa fácil identificar o erro, porque para configurá-lo não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova. Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé. Temos, assim, no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição, uma norma que cuida especificamente da responsabilidade do Estado por atos judiciais, enquanto a norma do art. 37, §6º, de natureza geral, aplica-se a toda a atividade administrativa. Destarte, se a função jurisdicional, como querem alguns, não se distingue ontologicamente da atividade administrativa do Estado, não haveria razão para o tratamento diferenciado estabelecido na própria Constituição quanto à responsabilidade do Estado pelos atos judiciais típicos. Mas, na realidade, diferenças essenciais existem, que não cabem ser aqui destacadas porque conhecidas desde os bancos escolares, tanto assim que os juízes gozam de garantias constitucionais para poderem exercer com independência a função de julgar. Quanto à coisa julgada, que não constitui obstáculo para os defensores da ampla responsabilidade do Estado por atos judiciais, antes de acolhermos posições tão avançadas é preciso ter em mente que a intangibilidade da coisa julgada não é mero dogma, mas sim princípio constitucional. Como reputar errada uma sentença transitada em julgado se ela é a lei do caso concreto, a vontade do Estado para determinada relação jurídica? Como provar que a decisão está errada sem o processo de rescisão? Como poderá a sentença remanescer entre as partes e ser considerada errada em face do Estado? A razão neste ponto está com o insigne Arruda Alvim: “Vale dizer, se há coisa julgada, enquanto esta estiver de pé, isto se constitui em elemento inibitório da responsabilidade civil do Estado; se passar o prazo dentro do qual poderia ter sido proposta ação rescisória e isto não ocorreu, não mais se poderá – em processo civil – falar em responsabilidade do Estado, salvo, eventualmente, se o Poder Judiciário, através do juiz, atentar conscientemente contra a coisa julgada anterior, causando danos. Por outras palavras, estando de pé o ato jurisdicional e não havendo meios para que o mesmo seja derrubado, tal se constitui em fator inibitório da responsabilidade civil do Estado” (Código de Processo Civil comentado, v. V/308).

Não estamos advogando a tese de que sempre necessária a ação rescisória ou a revisão criminal para que possa ter lugar a indenização por erro judicial. A exigência da desconstituição do julgado como pré-condição, obviamente, só se refere à decisão de mérito. Casos poderão ocorrer em que o erro judicial fique desde logo evidenciado, tornando possível a imediata ação de indenização, como, por exemplo, o excesso de tempo de prisão por omissão, esquecimento ou equívoco; prisão da pessoa errada por homonímia; atos praticados com abuso de autoridade – prisão sem formalidades legais, não relaxamento de prisão ilegal etc. o que não nos parece aceitável é a amplitude que vem se procurando dar ao conceito erro judicial, ao ponto de considerá-lo sinônimo de falta de prova. O benefício da dúvida, que no Direito Penal leva à absolvição do réu (in dubio pro reo), não tem o condão de servir de fundamento para a reparação civil. Falta de prova não é sinônimo de erro judicial, nem mesmo lato sensu.

(...)

No que respeita aos danos causados pela atividade judiciária, aqui compreendidos os casos de denegação da justiça pelo juiz, negligência no exercício da atividade, falta do serviço judiciário, desídia dos serventuários, mazela do aparelhamento policial, é cabível a responsabilidade do Estado amplamente com base no art. 37, §6º, da Constituição ou na culpa anônima (falta do serviço), pois trata-se, agora

sim, de atividade administrativa realizada pelo Poder Judiciário. Com efeito, danos graves e de difícil reparação podem resultar para as partes em razão da negligência do juiz no cumprimento do seu dever: prolongamento abusivo de prisões preventivas; vazamento indevido de informações sobre certos processos para órgãos de imprensa – o que contribui para que se projete uma certeza de culpa, antes do julgamento; a espetacularização de prisões, cobertas pela mídia, com a colocação de algemas em pessoas que nunca empunharam uma arma de fogo; a divulgação de gravações telefônicas sigilosas, trechos de conversas totalmente fora de contexto e sem que se tenha nenhuma certeza de sua autenticidade ; o retardamento injustificado da decisão, além de outras hipóteses de denegação da justiça. Por seu turno, o serviço judiciário defeituoso, mal organizado, sem os instrumentos materiais e humanos adequados, pode, igualmente, tornar inútil a prestação jurisdicional e acarretar graves prejuízos aos jurisdicionados pela excessiva morosidade na tramitação do processo. Os bens das partes se deterioram, o devedor desaparece, o patrimônio do litigante se esvai etc.

Ora, já ficou assentado que o arcabouço da responsabilidade estatal está estruturado sobre o princípio da organização e do funcionamento do serviço público. E, sendo a prestação da justiça um serviço público essencial, tal como outros prestados Pelo poder Executivo, não há como e nem por que escusar o Estado de responder pelos danos decorrentes da negligência judiciária, ou do mau funcionamento da Justiça, sem que isso moleste a soberania do Judiciário ou afronte o princípio da autoridade da coisa julgada.

Esta é a posição assumida pela melhor e mais atual doutrina brasileira, e que já começa a repercutir na jurisprudência, em consonância com a grande abrangência que a Constituição de 1988 deu à responsabilidade do Estado. Confira-se.

“Responsabilidade civil do Estado – Atividade judiciária – Prisão indevida – dano moral caracterizado – Indenização – Quantificação dotada de razoabilidade – Honorários advocatícios.

A prova do dano está no próprio fato que o ensejou, ou seja, a prisão do autor quando a autoridade judiciária já tinha determinado o recolhimento do mandado anteriormente expedido. É cabível a responsabilidade do Estado, com base no art. 37§6º, da Constituição Federal, quando se tratar de danos causados pela atividade judiciária realizada pelo Poder Judiciário. A indenização foi fixada com razoabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto, não representando uma vantagem pecuniária para o ofendido, nem caracterizando o enriquecimento sem causa. Tratando-se de ação de indenização cujo valor pleiteado é meramente estimativo, não ocorre a sucumbência parcial se a condenação fixada na sentença é inferior àquele montante. Recurso desprovido”. TJRJ, Ap. cível 23.325/2001 (2ª C. Cív., Rel. des. Elisabete Filizzola).

“Responsabilidade civil do Estado – Risco administrativo – Atos do Poder Judiciário – O princípio estatuído pelo §6º da Carta Política no tocante à atividade jurisdicional sofre temperamento advindo da regra do art. 5º, nº LXXV, que restringe a responsabilidade estatal aos casos de erro judiciário ou prisão ilegal. A prisão preventiva, regularmente decretada, tem respaldo constitucional – art. 5º, nº LXI – e a superveniente absolvição do preso, fundada em insuficiência de provas, não fazendo coisa julgada no campo civil, não tem o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória. O dever do Estado, de manter a tranquilidade e a ordem públicas, não se compadece com a leniência do trato com os delinquentes” TJRJ Ap. cível 5.428/96 (9ªC., Rel. Des. Carlos Motta).”

Bem.

A responsabilidade civil decorrente de dano causado por agente público, em função estatal, a terceiro, isto é, pessoa sem vínculo com o Estado, tem seu suporte fático hipotético definido, exclusivamente, no artigo 37, §6º, da CRFB, entrando o Código Civil para a definição suplementar de seus pressupostos (nexo causal e dano e sua extensão, por exemplo). Segundo a regra constitucional: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nada importa se ato comissivo ou omissivo, por dano material ou moral, tem seu suporte fático trazido pelo artigo 37, §6º, da CRFB (CC, artigo 43). Embora a obrigação de reparar o dano prescindida da culpa, não há como afastar a existência de nexos causal entre o alegado prejuízo e alguma conduta ou dever relacionados à Administração.

O dano causado pela atividade estatal a terceiro independe da investigação de culpa do agente público deflagrador do resultado danoso. Basta a qualidade de agente estatal, este compondo os quadros funcionais por qualquer vínculo ao Estado (investidura), àquele que comete o ato danoso e que o fato ocorra em atividade estatal, ou em razão dela.

Aplica-se, outrossim, ao caso a Teoria do Órgão Administrativo. Há responsabilidade civil do ente público ao verificar-se a ocorrência de ato ou de omissão por parte do ente, tanto pela prática do que não devia, juridicamente, ter sido praticado, ou de ato que deveria ter sido cometido e não o foi, atribuídos a um agente público (identificado ou identificável), ou ao grupo identificado, ainda que sem identificação do agente público.

Não há que provar que houve culpa administrativa por ter elegido mal o funcionário para tal atividade ou função. Bastarão o nexos causal entre a atividade pública exercida por aquele e o dano sofrido pelo particular e a ausência de fato que atue na causalidade, excluindo ou atenuando a responsabilidade estatal. Enfim, responde o ente estatal simplesmente porque causou dano ao administrado.

Unicamente não haverá responsabilidade do ente público se este, por seus agentes, não causou o dano ao particular ou se inexistente relação causal entre o prejuízo e a atividade pública, isto é, a causa do dano foi outra. A existência ou não de culpa de funcionário é desimportante ao suporte fático do artigo 37, §6º, da CRFB e, acrescente-se, impossível de ser investigada na responsabilidade civil extracontratual do Estado. Seria objeto de investigação se o dano tivesse sua fonte nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.

Quanto ao mérito, desde logo é importante destacar o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Também merece transcrição o disposto no § 6.º, do artigo 37, da Constituição Federal:

§ 6.º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por fim.

Todos os elementos da responsabilidade civil devem existir e ser provados pelo ofendido, pois compreendem em fato constitutivo de seu direito. As excludentes são

fatos jurídicos impeditivos do direito do ofendido, devendo, portanto, ser comprovadas em Juízo pelo suposto agressor.

Em outras letras, a existência de responsabilidade sem nexo subjetivo (culpa ou dolo) não implica em responsabilidade automática. A lei traz alguns fatos ou situações que afastam o dever de indenizar, como as excludentes de responsabilidade, tornando legítimo o prejuízo causado. Na responsabilidade civil objetiva, não há de falar em incidência de excludentes de ilicitude (CC, artigo 188); na modalidade objetiva, o dano está adequadamente afeto ao virtual ofensor ou não está (se a vítima, terceiro ou outro fato causou-o).

Ainda, não se pode olvidar de que algumas decisões no processo penal, presumidamente com rito mais garantidor de direitos constitucionais de defesa do acusado, refletem obrigatoriamente efeitos no direito material civil (responsabilidade civil), devendo o Juízo Civil obedecer a tais comandos, como o da norma do artigo 65 do CPP, e de algumas hipóteses de sentença absolutória, devendo sempre ter em mente que não há correspondência absoluta da decisão processual penal no Cível (ex.: o artigo 188 do CC não prevê o estado de necessidade, situação esta prevista no CPP), além de que o dano causado à vítima não pode ultrapassar limites do razoável para salvaguardar direito.

No caso concreto, o autor foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 217 do Código Penal.

Estabelece o Artigo 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

- I - 16% (dezesesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
- II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
- III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
- IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
- V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
- VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
 - a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
 - b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
 - c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
- VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
- VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes.

(...)

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Como visto, o cumprimento do requisito temporal é apenas uma das condições para a progressão de regime, cabendo, ainda, verificação acerca do comportamento carcerário e inexistência de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade. Trata-se, portanto, de pedido que deve ser analisado de acordo com cada caso concreto, e não um direito subjetivo do detento após o mero cumprimento do tempo necessário. A lei é expressa acerca da necessidade de motivação na decisão do juiz que autoriza a progressão de regime, bem como sobre a imprescindibilidade de manifestação prévia do Ministério Público.

Ademais, a progressão será concedida quando o preso tiver cumprido ao menos a fração de tempo indicada na legislação processual penal. Em outras letras, não há abusividade ou ilegalidade na manutenção no regime mais gravoso por tempo superior, e tampouco pode ser considerado erro judiciário, a ensejar a indenização prevista no Artigo LXXV da Constituição Federal.

Com efeito, eventual demora na concessão da progressão de pena não pode ser confundida com excesso de prisão, visto que o término do cumprimento da pena do autor está previsto para 20 de setembro de 2027 (fls. 130).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS POR ERRO JUDICIÁRIO - Alegação de prisão ilegal no regime semiaberto, tendo em vista desídia dos agentes públicos na concessão de progressão para o regime aberto - Inocorrência - Inteligência dos artigos 112 e seguintes da Lei de Execução Penal - Permanência no regime anterior por período superior ao de um sexto da pena não constitui ato abusivo ou ilegal, muito menos configura erro judiciário - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012578-27.2019.8.26.0320; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

APELAÇÃO - Ação indenizatória - Danos morais - Alegado erro judiciário no cálculo de pena e demora na apreciação do pedido, o que teria resultado no mantimento por 18 (dezoito) meses em regimes de encarceramento mais gravosos - Responsabilidade civil subjetiva "Faute du service" - Ausência de comprovação - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000659-95.2020.8.26.0032; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por Marcial Oliveira Beraldo em face da FESP e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Indevido o pagamento de custas e despesas nesta fase processual, nos termos do

artigo 27 da Lei 12.153/2009 c.c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

P. R I.

Bauru, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA